

1500399-15.2021.8.26.0617

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Loureiro Sobrinho

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/07/2022

... e "guardar".

O fim específico de tráfico não é elemento subjetivo do tipo, o qual não prevê dolo específico, decorrendo da subsunção da conduta a um dos verbos descritos nele. O tráfico está assim caracterizado, devendo-se comprovar o elemento específico apenas nos casos do artigo 28, da Lei 11.343/06, ou seja, o uso próprio.

Mas, mesmo se assim não fosse, o fim de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

1ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, São José dos Campos-SP - cep 12246-260

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500399-15.2021.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500399-15.2021.8.26.0617

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2079762/2021 - DISE- DEL.SEC.S.J. DOS CAMPOS, 16920878 - DISE- DEL.SEC.S.J. DOS CAMPOS, 44/21/328 - DISE- DEL.SEC.S.J. DOS CAMPOS, 2079762 - DISE- DEL.SEC.S.J. DOS CAMPOS, 2079762 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 1, 44/21/328 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 1

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO MENDES PINTO e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Loureiro Sobrinho

Vistos.

1. MARCELO MENDES PINTO e CLAYTON VINICIUS DE FARIA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, § 1º, I e II e artigo 35, "caput", ambos da Lei 11.343/06, porque na data e local descritos na denúncia, agindo com consciência e vontade livres, após associaram-se para o fim de cometerem tráfico ilícito, de forma reiterada ou não, respectivamente, semeavam, cultivavam, tinham em depósito e guardavam, substâncias entorpecentes, a saber, 09 pés grandes e 17 pés menores de

maconha, pesando 2190,3 gramas e 56,82 gramas, respectivamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Os réus foram notificados.

Defesa prévia foi apresentada.

A denúncia foi recebida.

Os réus foram citados e, em audiência de instrução debates e julgamento, realizada em por videoconferência pelo sistema teams, foram ouvidas testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, procedendo-se, enfim, ao interrogatório dos réus.

Em memoriais, o representante do Ministério Público pleiteou a procedência da ação penal, nos termos da denúncia, com a consequente condenação dos réus. A defesa pugnou pela absolvição, nos termos do artigo 386, V e VII, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, a desclassificação do delito para porte de droga para uso próprio, ou, subsidiariamente, a redução máxima prevista na Lei de Drogas, substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, estabelecimento da multa nos moldes do Código Penal, e concessão do direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

DECIDO.

2.A ação penal deve ser julgada parcialmente procedente.

A materialidade do delito de tráfico está comprovada pelo laudo de exame químico toxicológico de fls., que apontou resultado positivo para cannabis sativa L, com a notável presença de tetrahidrocannabinol (THC), não merecendo reparo, pois bem se utilizou da boa técnica existente.

A autoria é indubitosa.

Os réus, em seus interrogatórios, negaram a acusação. Disseram, em síntese, que realmente cultivavam maconha em suas residências, mais precisamente em um dos quartos da casa onde ambos moravam. Esclareceram, contudo, que a droga se destinava para seu uso próprio, destacando que os policiais civis compareceram no local e apreenderam os pés de maconha, conduzindo-os injustamente presos até a Delegacia de Polícia.

Tais versões, contudo, não podem ser levadas em conta, pois inconsistentes e incoerentes, não encontrando respaldo no isento conjunto probatório.

A prova oral, por sua vez, corroborou, em parte, os fatos descritos na denúncia. As testemunhas ouvidas, policiais civis, de maneira firme e coerente, informaram que havia denúncia anônima de que no local dos fatos havia um laboratório de droga para fins de tráfico ilegal, especificamente maconha especial e de melhor qualidade, destinada a um público diferenciado com melhor poder aquisitivo. Assim, de posse de regular mandado de busca regularmente expedido por este Juízo, foram até o local dos fatos, constatando a presença de ambos os réus na residência, os quais confirmaram que ali moravam. Então, em um dos quartos da casa havia espécie de laboratório, de estufa com diversos pés de maconha, consoante descrito na inicial, destacando-se que ali havia iluminação especial, aeração especial, adubação especial, inclusive importada, painéis led, termômetros, sistema hidropônico de bomba de água, etc.. Enfim, perceberam que se tratava de um cultivo realmente diferenciado de maconha especial, hidropônica inclusive e de melhor qualidade. No mais, uma vez indagados os réus afirmaram que realmente cultivavam as drogas, que lhes pertenciam, mas para uso próprio. Finalmente, foram ambos conduzidos presos até a Delegacia de Polícia.

Já a testemunha arrolada exclusivamente pela defesa, pouco ou nada acrescentou ao conjunto probatório, pois destacou não ter presenciado especificamente a diligência policial em questão, limitando-se a prestar detalhes abonadores da vida pregressa do réu.

Diante desse quadro, percebe-se que o conjunto probatório aponta, de forma suficiente, terem os réus realizado o delito previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06, em suas elementares, na forma descrita na denúncia.

O conceito de suficiência, não se confunde, para efeito de condenação, com isenção total de eiva indubitativa, consiste, pois, na firme possibilidade de afirmação da realidade do fato imputado e de definição de sua autoria, no contexto das

comprimidas fronteiras humanas da capacidade de apreensão dos elementos probatórios e de reconstituição do episódio delituoso. Prova suficiente não é nem pode ser penhor de certeza plena, de que somente os deuses são senhores. Daí se afigura irreal e meramente retórico o emprego de expressões como “prova categórica”, “prova cabal”, e outras do gênero.

Bem assim, há prova suficiente de que a substância entorpecente foi encontrada em poder dos réus, o que, por si só, autoriza a condenação.

Autoriza porque, desta forma, os réus praticaram a conduta típica prevista no artigo 33, da Lei 11.343/06, incidindo em pelo menos quatro dos verbos descritos na figura típica, quais sejam, “semear”, “cultivar”, “ter em depósito” e “guardar”. O fim específico de tráfico não é elemento subjetivo do tipo, o qual não prevê dolo específico, decorrendo da subsunção da conduta a um dos verbos descritos nele. O tráfico está assim caracterizado, devendo-se comprovar o elemento específico apenas nos casos do artigo 28, da Lei 11.343/06, ou seja, o uso próprio.

Mas, mesmo se assim não fosse, o fim de mercancia ilícita está demonstrado ante as peculiaridades do caso, ou melhor, a considerável quantidade e a forma em que o entorpecente estava separado, a denúncia anônima do tráfico no local dos fatos de maconha especial, destinada a um público diferenciado e o encontro de petrechos relacionados ao tráfico, tais como verdadeiro laboratório para preparo de drogas, onde havia diversas plantas com a presença do princípio ativo da droga, no caso THC, adubação especial, iluminação especial, aeração especial, painéis de led, termômetros e sistema hidropônico de bomba de água, apontam para fins de comercialização, para repasse a terceiros.

O fato da substância entorpecente ter sido encontrada em poder dos réus, inverte o ônus da prova, impondo-lhe justificativa verossímil, fazendo incidir sobre ela presunção de culpabilidade.

No caso presente, os réus não fizeram prova suficiente nesse sentido, pois se invertendo o ônus da prova, a suficiência probatória, agora para afastar ou, pelo menos, estabelecer a dúvida sobre a acusação, compete a eles.

Não se diga que o testemunho de policiais deva ser recebido com reservas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. Pelo contrário, o testemunho de policiais deve merecer credibilidade, pois não faz sentido que eles, credenciados pelo Estado para atuarem na repressão e na prevenção delitiva, sejam desconsiderados, quando compromissados, como qualquer outra testemunha, que vêm a juízo relatar diligências a que procederam no exercício de suas funções.

Quanto à co-autoria, frise-se que, nos termos do artigo 29, “caput”, do Código Penal, quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominada, na medida de sua culpabilidade.

“Co-autoria 'é a realização conjunta de um delito por várias pessoas que colaboram consciente e voluntariamente' (Muñoz Conde, Teoría General del Delito, 1984, pg. 292). Cada co-autor é um autor e, por isso, deve apresentar as características próprias do autor. Isto significa que o co-autor 'é aquele autor que tem o domínio da realização do fato conjuntamente com outro ou outros autores, com os quais tem um plano comum e uma distribuições de funções na realização do mútuo acordo' (Juan Bustos Ramírez, Manual de Derecho Penal Español, 1984, pg. 331)”.

“A co-autoria é nada mais nada menos, em última análise, a própria autoria. Funda-se ela sobre o princípio da divisão do trabalho; cada autor colabora com sua parte no fato, a parte dos demais, na totalidade do delito e, por isso, responde pelo todo. Há na co-autoria, a decisão comum para a realização do resultado e a execução da conduta”.

Diante do conjunto probatório, tudo leva a crer que os corréus são co-autores, porque, de qualquer modo, contribuíram para o crime, estando previamente associados entre si e com unidade de propósitos, tendo o domínio final do fato típico, o qual praticaram, não podendo ser considerados como meros partícipes, vez que nenhum deles simplesmente apenas contribuiu auxiliando a conduta do outro.

Por outro lado, comprovado não está o delito previsto no artigo 35, “caput”, da Lei 11343/06.

Não é o simples concurso de pessoas que caracteriza associação. Necessário é o “animus” associativo prévio, sem dúvida uma “societas sceleris”. Necessária é a

comprovação de tal elemento do tipo, ou seja, vínculo associativo de caráter permanente, duradouro, que se depreende de vários elementos tais como reuniões prévias, base de operação, níveis de lucros presumidos, etc., o que não corre nos autos.

Destarte, comprovadas a materialidade e a autoria pelo delito de tráfico ilegal de drogas, impõe-se a condenação e por insuficiência probatória se impõe a absolvição quanto ao crime de associação para tal fim.

Na aplicação da pena, sopesadas as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, as penas-base devem ser fixadas no mínimo legal.

Na aplicação da pena, sopesadas as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, as penas-base devem ser fixadas no mínimo legal, não se aplicando a redução de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, pois há prova bastante de se dedicarem os réus a atividades criminosas, tendo em vista o encontro de considerável quantidade de droga, em verdadeiro laboratório com adubação especial, iluminação especial, aeração especial, painéis led, termômetros e sistema hidropônico de bomba de água, destacando-se a denúncia anônima de que no local havia maconha especial destinada à venda diferenciada para pessoas com melhor poder aquisitivo, o que foi confirmando em diligência, demonstrando-se de forma clara que os réus estavam a fazer do odioso tráfico de drogas seus meios de vidas, em ação coordenada e com divisão de tarefas.

Em razão das condições econômicas dos réus, a unidade do dia multa deve ser fixada no mínimo legal, devendo ser aplicado, neste ponto, o previsto na Lei 11.343/06, em razão do princípio da especialidade.

3. Posto isso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal e

ABSOLVO os réus MARCELO MENDES PINTO e CLAYTON VINICIUS DE FARIA, qualificados nos atos, da imputação a eles feita na denúncia pela infração penal prevista no artigo 35, da Lei 11.343/06, e o faço por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal;

CONDENO os réus MARCELO MENDES PINTO e CLAYTON VINICIUS DE FARIA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 à pena de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, com unidade fixada no mínimo legal.

Não fazem os réus jus ao benefício da substituição da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, do Código Penal, pois o crime de tráfico de drogas é grave, equiparado inclusive ao hediondo. Ainda, o delito em questão está capitulado em Lei Especial (nº 11.343/06), e tal, em seu artigo 33, § 4º, veda expressamente o aludido benefício, o qual nada tem de inconstitucional, pois apenas atende ao princípio de individualização da pena, observando a gravidade intrínseca do crime em questão. Mesmo se isso não bastasse, no caso, a quantidade de pena imposta impede este direito subjetivo ao réu.

Pelos mesmos motivos, o regime inicial para cumprimento das penas deverá ser o fechado, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal e artigo 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, com a nova redação que lhe foi dada, mas notada e precipuamente, porque assim recomendam os elementos concretos e individualizados, ante a gravidade do tráfico em questão, que na situação concreta, não provém de simples abstrações, suposições ou meras presunções, mas, sim, da situação fática descrita na denúncia, consistente na apreensão de considerável quantidade de droga, acondicionada em diversas plantas, droga essa especial, pois cultivada de forma sofisticada em laboratório e destinada à venda para pessoas diferenciadas, com maior poder aquisitivo, o que não só põe em relevo a periculosidade dos agentes, como também justifica e autoriza regime inicial mais gravoso.

Contudo, muito embora a gravidade do delito em questão, tráfico ilícito de maconha acondicionada em diversas plantas, preparadas em sofisticado laboratório, a denotar que os réus faziam do tráfico seu meio de vida, vendendo drogas especiais a pessoas diferenciadas, com maior poder aquisitivo, no caso dos autos, responderam em liberdade ao presente processo, não frustrando a instrução criminal e a aplicação da Lei Penal, fazendo, pois, jus ao benefício de recorrer em liberdade.

P.R.I.C.

São José dos Campos, 19 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA